

1500213-84.2022.8.26.0575
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES
Comarca: São José do Rio Pardo
Foro: Foro de São José do Rio Pardo
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 26/07/2022
... Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José do Rio Pardo
Foro de São José do Rio Pardo
1ª Vara
Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500213-84.2022.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500213-84.2022.8.26.0575
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092036/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 24070036 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 636/22/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2092036 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELIZABETE CRISTINA TEODORO e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Elizabete Cristina Teodoro e Gustavo Luis Maria, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 04 de

abril de 2022, no período da tarde, por volta das 15h30, na Rua Pedro Bagodi, Jd. Eunice, Colinas São José, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, vendiam e traziam com eles, para fins de tráfico, 161 (cento e sessenta e um) pedras de crack, substância feita à base de cocaína, pesando cerca de 57,3 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular.

Prisão em flagrante convertida em preventiva na decisão de págs. 63/73.

A denúncia de págs. 116/118 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/59.

Os réus foram notificados (págs. 131 e 133) e apresentaram defesa prévia (págs. 147/152) alegando a inexistência de justa causa para a promoção de ação penal em desfavor dos denunciados, sobre a premissa de não existir provas concretas de que os réus praticavam tráfico de drogas. Requer sejam os denunciados submetidos a exame de dependência de substância entorpecente, bem como a rejeição da denúncia. Requer a liberdade provisória.

Pedido de liberdade provisória indeferido (págs. 175/176).

A denúncia foi recebida aos 19 de maio de 2022, designando-se audiência de instrução para o dia 15 de junho de 2022 (págs. 153/155).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ - pgs. 200/202.

Foi determinada a juntada da carta mencionada pela presa Elizabete, conforme deliberação de pgs. 202.

O documento encontra-se nas pgs. 204/205.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Após exposição da prova oral, conclui que a negativa dos réus está isolada. A carta apresentada não inocenta Elizabete e os depoimentos dos policiais foram seguros e precisos no sentido da traficância. Requer o aumento da pena base diante da quantidade de droga apreendida, ressaltando as condenações de Elizabete e a tentativa de Gustavo induzir o juízo em erro. Pugna pelo regime inicial fechado - pgs. 212/218.

A defesa, por sua vez, reiterou o pedido de submissão dos réus a exame de dependência toxicológica. No mérito, sustenta que os depoimentos dos policiais não servem como meio de prova, pois interessados em demonstrar que o trabalho realizado está correto, restando suspeitos. Indica que Elizabete possui 3 filhos menores e que não há prova alguma de que a droga destinava-se ao comércio, pois os policiais não ouviram qualquer testemunha. Requer a desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, ressaltando que não há provas de autoria de tráfico propriamente dito. Requer a absolvição dos réus, na forma dos incisos II e V do art. 386 do CPP ou a desclassificação da conduta. Alternativamente, pugna pela pena na forma privilegiada do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas - pgs. 219/226.

DECIDO.

1 -) QUESTÃO PRÉVIA

A defesa reiterou o pedido para instauração de incidente de exame de dependência toxicológica.

Todavia, não há necessidade de tal prova.

O art. 149 do CPP preceitua que somente a dúvida relevante acerca da integridade mental do acusado legitima a realização de exame de dependência toxicológica, para fins de constatação de insanidade mental.

Os réus, interrogados, responderam com absoluta clareza às indagações de Juízo e das partes, de modo que nada evidencia que tenham suas capacidades de discernimento comprometidas pelo uso de entorpecentes.

O cometimento do delito sob eventual efeito de drogas ou álcool não afasta a imputabilidade do réu conforme a teoria da 'actio libera in causa', uma vez que não se trata de utilização decorrente de caso fortuito ou força maior, e sim de consumo voluntário.

Como sabido, "A tão só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas não torna obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato." (STJ, Quinta Turma, HC 118970, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 07.02.2011).

O juiz pode indeferir o pedido de instauração de incidente de Dependência Toxicológica, em decisão fundamentada, demonstrando as razões pelas quais considera dispensável a sua realização (APR nº 20160910037182 (980891), 3ª Turma Criminal do TJDF, Rel. Sandoval Oliveira. j. 17.11.2016, DJe 21.11.2016)

Não há documentos médicos indicando drogadição acentuada dos réus a ponto de recomendar a submissão à avaliação pericial.

Assim, inexistindo indícios de que sofreram redução na sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento, justificado se encontra o indeferimento do pedido de realização de incidente de dependência toxicológica, o qual, uma vez deferido, representaria, provavelmente, produção de prova meramente protelatória.

2 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

2.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 17/18), auto de constatação preliminar (págs. 19/20), além do exame químico-toxicológico de págs. 139/144, que indica que a massa líquida da substância foi de 3,34 + 22,3 gramas, totalizando 25,64 gramas.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Rivaldo Luciano Tonhão confirma que o local da abordagem é o "buracão" conhecido ponto de tráfico e ficaram observando a movimentação do Gustavo, conhecido dos

meios policiais, assim como a ré. Ela pegava dinheiro dos usuários e entregava para o Gustavo e vice-versa. Observaram umas 3 movimentações. Ela dispensou um flaconete verde com pedras de crack. O Gustavo tinha uma pochete com mais de uma centena de pedras de crack. O Gustavo era bastante conhecido e havia denúncias de que abastecia a biqueira do buracão. Nenhum dos dois aparentava que estava sob efeito de drogas. Eles disseram que eram namorados. Ali ficam os usuários e os traficantes no meio para disfarçar. Dificilmente eles guardam as drogas no corpo. Geralmente escondem. Quando tem drogas com eles, geralmente é pouco. Não houve explicação sobre o dinheiro e a droga. Ficaram observando a uma distância de uns 20 a 30 metros, não mais do que isso. Visualizaram umas 3 ou 4 vendas. A campana aguardou uns 20 minutos a 25 minutos. Diante dessa observação tiveram clareza de que os dois estavam passando drogas e não apenas fumando crack. Havia outras pessoas no local, mas quando chegaram o pessoal saiu correndo. Abordaram apenas os dois que estavam traficando realmente. Não deu para ouvir usuário porque o local é difícil. Estavam em dois policiais e o pessoal correu. Não filmaram dessa vez.

João Paulo Gonçalves Parra relata que o local é conhecido como "buracão" onde ocorre intenso tráfico de drogas. Observaram um casal ativo na movimentação. Viram 3 ou 4 vendas. Eles se revezaram. Eles entregavam drogas para os usuários. A moça dispensou um flaconete no chão e o Gustavo uma pochete. No flaconete havia 25 pedras e o restante com o Gustavo. Eles não aparentavam que estavam sob o efeito de drogas. Ambos eram conhecidos dos meios policiais, Gutinho e Bete. Ali no local muitos usuários frequentam. Os usuários, em algum momento do dia, tem que fazer uma "cota". Para poder ficar ali os usuários têm que desempenhar alguma função. Estavam de 20 a 30 metros, no meio das árvores. A campana durou uns 20 minutos. Conseguiu ter clareza de que os réus estavam passando drogas e não apenas usando crack ali. Eles negaram que estivessem traficando. O perfil do tráfico no "buracão" é que os usuários permanecem próximos aos que estão vendendo para disfarçar. O local é conhecido como a "crackolândia" de São José. Não havia mais ninguém no local porque quando foram chegando as outras pessoas foram saindo. Não foi possível abordar nenhum usuário porque eram muitos indivíduos. Traficando era apenas o casal. Os demais estavam apenas usando o entorpecente. Não foi feita filmagem. Tiveram certeza que eles não eram usuários porque ela dispensou o flaconete e ele a pochete. Eles não eram usuários e sim traficante.

O réu Elizabete Cristina Teodoro, 30 anos. É faxineira e já cuidou de idosos. Nunca foi presa ou processada. Tem 3 filhos de 13, 12 e 9 anos. Perdeu a guarda de dois filhos por causa do vício e um filho está na sua guarda, a de 13 anos. Agora ela está com a sua tia, que é sua mãe de criação. Elas moram juntas. O seu vício é crack. Faz 15 anos que é dependente química e teve 3 internações por causa das 3 gravidez. O Gustavo não é nada seu, apenas fazia programa com ele em troca de droga. Ouviu o que os policiais disseram e está totalmente errado. Estava sentada com os demais usuários usando droga e Gustavo estava com a depoente, no meio. Gustavo estava com um potinho verde e jogou para cima da depoente quando a polícia chegou. A polícia mandou os demais usuários sair e apontou a arma para o Gustavo, falando o nome dele completo. O outro policial lhe abordou e deu 3 tapas no rosto. Colocaram a depoente num quartinho e o Gustavo mandava a depoente assumir que a droga era sua porque ele já tinha passagens. Na delegacia não pode falar nada. Foi para São João e ele foi para Casa Branca e não teve oportunidade de falar. Chegou uma carta para a depoente. A carta seria do Gustavo e é a prova da sua inocência. Ele pede para a depoente assumir os 25 papéis. É apenas usuária de crack de São Sebastião da Gramma. Frequentava a matinha apenas para comprar a droga. Ele xinga na carta, mas não sabe se tem ameaça. Ele fez opressão. Ele falou que tinha conversado com advogado e acha que é mentira. Ele não tem advogado particular. O advogado teria mandado a depoente assumir que para ela não daria nada. Foi para o regime semiaberto por causa de uma munição de calibre 22. Foi pega com pés de maconha em Vargem Grande do Sul.

O réu Gustavo Luis Maria foi processado anteriormente e fazia uns 3 anos que estava em liberdade. Começou a fumar crack de novo. Tem 28 anos. Trabalhava na roça.

Morava no buracão, na rua. Estava usando crack. A Elizabete é sua amiga. Ouviu o que os policiais disseram. Eles pegaram o depoente com o cachimbo na mão. Deram uma bicuda e jogaram o cachimbo fora. Eles cataram a pedra em cima do cachimbo. Abordaram o depoente e não acharam nada. A Elizabete estava do lado do depoente. Estavam numa rodinha com uns 10. Ninguém correu. Eles chegaram, abordaram, deram umas bicudas em todo mundo e mandaram todo mundo sair correndo. Eles bateram na cara da Elizabete. Jogaram ela no chão. A droga não é sua, nem da Elizabete. É usuário. Foi colocado para fora de casa. Quem dispensou a droga foram os moleques em quem eles deram umas bicudas. Começaram a bater na cara dela. O dinheiro também não era deles. Era de um tal de Bruno que saiu correndo. Estudou até a quinta série e sabe ler e escrever normal. Reitera que a droga não era sua e estava ali fumando apenas. Estava vendendo as coisas em casa para comprar crack.

3 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial. Em suas versões, os policiais narraram claramente atos de traficância.

Nada faz crer que os policiais estejam agindo imbuídos por sentimentos subalternos dignos de censura tendentes a elucubrar versão incriminadora para aprisionar injustamente pessoas com as quais não mantêm qualquer relação de desafeto comprovada.

Por outro lado, em que pese a presunção de inocência e a possibilidade dogmática de incidência do benefício da dúvida é preciso lembrar que o artigo 156 do Código de Processo Penal é categórico no sentido de que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Inexistente contraprova hábil a desqualificar a prova acusatória, o Juízo deve orientar-se pela verdade processual objetivamente existente no processo, sem margem para decisionismo ou dúvida subjetiva. A dúvida deve estar alicerçada na insuficiência de provas ou na existência de provas com versões conflitantes, antagônicas.

Não é possível externar convicção motivada a partir de ilações particulares do julgador, pois a motivação jurídica decorre do processo de persuasão racional, assim entendido como aquele que pode ser devidamente explicado com base nos

elementos presentes no processo e não no âmago psicológico da entidade decidente.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEIMALATESTA, o qual afirma que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado” (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 destaque do Juízo)

As alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que o fiel da balança incline-se no sentido oposto à pretensão ministerial.

A carta exibida pela ré acabou por lhe prejudicar. Longe de evidenciar que apenas Gustavo estava traficando, a missiva permite entrever claramente que os dois estavam mancomunados e que Gustavo pretendia que Elizabete assumisse sozinha a traficância porque não ficaria presa nem seis meses.

Destarte, não há campo para desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco para absolvição dos réus, pois ambos os policiais empenhados na diligência são experientes e sabem discernir atos de entrega de drogas ao consumo de terceiros ou a simples permanência no grupo de usuários que frequenta aquela conhecida “biqueira”.

No que tange à alegada drogadição, é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, “Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figurado viciado-traficante” (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Presente a tipicidade delitiva na forma imputada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade dos réus, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

4 -) DO DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 116/118, para CONDENAR ELIZABETE CRISTINA TEODORO pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e e GUSTAVO LUIS MARIA pela prática do crime capitulado no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Primeiramente em relação à ré Elizabete, analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

No entanto, o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 25,64 gramas, conforme págs. 139/144.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo não encontra campo para acréscimo, uma vez que a quantidade apreendida está dentro dos padrões das apreensões normais e corriqueiras nesta comarca. A massa líquida é de poucas gramas e não permite qualquer acréscimo na pena.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

Elizabete foi condenada definitivamente nos autos do processo » Juizado Especial Cível e Criminal. Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo: 0000857-38.2017.8.26.0588 Situação: Extinto. Data: 30/08/2017. Autor: Justiça Pública. Transitado em julgado para a defesa aos 18.05.2018 - pg. 43.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, na proporção de 1/6 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Além da condenação supra, Elizabete também foi condenada definitivamente nos autos dos processos » Vargem Grande do Sul - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo: 0000643-80.2016.8.26.0653 - trânsito em julgado em 28.07.2017.

Assim, por força da reincidência, novo acréscimo se impõe a fim de que a pena seja alçada ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Descabida a minorante do § 4º do art. 33 diante dos maus antecedentes e reincidência.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA apenas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Quanto ao regime prisional deve ser o inicialmente FECHADO, pois mantido o caráter equiparado a hediondo da conduta. Além disso, a ré é reincidente e ostenta maus antecedentes tendo experimentado condenação no mesmo regime e não se ressocializou. Destarte, a imposição de regime menos rigoroso mostra-se claramente inadequada ao seu perfil.

Não permito que recorra em liberdade, pois respondeu ao processo presa e após regular instrução fortaleceram-se os indícios de autoria. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontra.

A pena de Gustavo é diversa.

Na primeira etapa verifica-se que a condenação nos autos 0001122-79.2017.8.26.0575 (também com o número 0007047-02.2017.8.26.0496) foi reformada, restando apenas sanções na forma do art. 28 da Lei de Drogas – pg. 46/47.

Este Juízo possui entendimento consolidado no sentido de que a condenação nas iras do art. 28 da Lei de Drogas não deve ensejar qualquer acréscimo na reprimenda de outro delito, pois o efeito reflexo da condenação não pode trazer maior gravame do que a própria pena prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador que sequer prevê pena privativa de liberdade.

No RHC 178.512 foi exatamente o entendimento do E. STF no sentido de que a condenação por posse de drogas não configura reincidência.

Assim, Gustavo deve ser considerado primário.

Todavia, reprovável que tenha tentado intimidar Elizabete a fim de que ela assumisse sozinha a propriedade das drogas, induzindo o Juízo em erro, como bem indicado pelo Ministério Público.

Tal conduta demonstra completa indiferença em relação à condição de mulher de sua parceira, o que sugere maior culpabilidade e necessidade de agravamento da pena base em 1/6.

Na primeira etapa a pena de Gustavo também fica fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, entretanto, não há agravantes ou atenuantes. Destarte, nenhuma alteração encontra campo.

Sendo diminuta a quantidade de drogas e primário o réu, faz jus à benesse do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Não há provas de ligação a organização criminosa, pois quantidade de drogas apreendida pode perfeitamente ter sido angariada junto a outros traficantes locais para revenda, sem que isso implique integração a qualquer organização criminosa ou associação para o tráfico. Desautorizada qualquer presunção prejudicial ao réu neste aspecto.

Também não é possível considerar que o envolvimento do réu com a traficância que acabou levando-o ao cárcere neste processo possa autorizar a imposição do óbice "não se dedicar a atividades criminosas", pois a habitualidade é inerente à traficância. Entender diversamente resultaria no esvaziamento da causa de redução de pena engendrada pelo Poder Legislativo, distorcendo a mens legis.

Diminuo a pena em 2/3 fixando-a no patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Onde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 509.578/SP (2019/0133777-0), STJ, Rel. Antônio Saldanha Palheiro DJe 16.05.2019. Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

Em caso análogo, ao apreciar a apelação nº. 0000032-53.2016.8.26.0613, a Colenda 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória proferida por este Juízo, mantendo igualmente a determinação de que o réu inicie o cumprimento da pena sob o regime aberto.

Também a 12ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação nº 0000322-85.2016.8.26.0575 desta comarca manteve o regime inicial aberto com expressa alusão às Súmulas 718 do STF e Súmula 440 do STJ, bem como ao HC STF nº 118.533.

A 16ª Câmara Criminal seguiu o mesmo norte na Apelação nº 0001003-55.2016.8.26.0575 desta Comarca, em acórdão da Relatoria do Eminentíssimo Desembargador Guilherme de Souza Nucci.

Para melhor ilustrar:

TJSP-) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PROFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM DESFAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PACIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DA TESE NO SENTIDO DA NÃO HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS, SE PRIVILEGIADO NOS MOLDES DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME ABERTO ESCOLHIDO PELO JUÍZO EM COERÊNCIA À QUANTIDADE DE PENA (01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS

DE RECLUSÃO), PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO AGENTE E DEMAIS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO APELO. (Apelação nº 0002209-93.2017.8.26.0438, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Diniz Fernando. j. 12.11.2018, Publ. 22.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM COMPROVAM A DESTINAÇÃO DO TÓXICO À MERCANCIA E NÃO AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO ACERTADA. QUANTIDADE DAS DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO RÉU QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E HEDIONDEZ DO CHAMADO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE FOI AFASTADA PELO PLENO DO E. STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E OUTRA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação nº 0000109-82.2018.8.26.0616, 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Francisco Bruno. j. 08.11.2018, Publ. 12.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - CONFIGURAÇÃO - DIMINUIÇÃO DO ACRÉSCIMO. PRIVILÉGIO - SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - MERA ILAÇÃO - QUANTIDADE POUCA EXPRESSIVA DE MACONHA - NEGATIVA INFUNDADA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS - CRITÉRIO - ART. 42 DO MESMO DIPLOMA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO - HEDIONDEZ AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS Nº 118.533. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. (Apelação nº 0003964-83.2015.8.26.0322, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Vico Mañas. j. 05.12.2018, Publ. 07.12.2018).

TJSP-) HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME PRISIONAL FECHADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ADMISSIBILIDADE - SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A MOTIVAÇÃO DA R. SENTENÇA, PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, NÃO SÓ PORQUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECLAROU A - INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL DISPOSITIVO, MAS TAMBÉM PORQUE O PRETÓRIO EXCELSO, NO HABEAS CORPUS Nº 118533/MS, AFASTOU A NATUREZA HEDIONDA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". ALIÁS, HÁ ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO, ACERCA DA NÃO HEDIONDEZ DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO", SEGUIDA POR ESTA COLENDIA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE EFEITO ERGA OMNES OU VINCULANTE DO R. DECISUM DAQUELA CORTE CONSTITUCIONAL, É DE BOM ALVITRE QUE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IGUALDADE, O ENTENDIMENTO EXTERNADO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 118.533 SEJA ADOTADO POR TODOS OS JUÍZES E TRIBUNAIS BRASILEIROS, EVITANDO-SE, COM ISSO, DECISÕES EM SENTIDOS OPOSTOS ACERCA DA MESMA MATÉRIA E QUE SOMENTE AQUELES ACUSADOS QUE POSSUAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA GALGAR TODAS AS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO SEJAM BENEFICIADOS PELOS EFEITOS DECORRENTES DA NOVA ORIENTAÇÃO DE QUE O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO POSSUI CARÁTER HEDIONDO. DE RESTO, CABÍVEL, EXCEPCIONALMENTE, O REGIME ABERTO EM FACE DO QUANTUM DA PENA E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus nº 2215577-73.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Moreira da Silva. j. 25.10.2018, Publ. 30.10.2018).

TJSP-) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - INDEFERIMENTO - CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - CÁLCULO QUE CONSIDEROU A HEDIONDEZ DO CRIME - INADMISSIBILIDADE - RECENTE JULGAMENTO DO STF QUE ENTENDEU NÃO SER HEDIONDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - HC 118533 - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DO STF - SÚMULA 512 DO STJ CANCELADA - NATUREZA HEDIONDA AFASTADA - CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DETENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - AGRAVO PROVIDO. (Agravado de Execução Penal nº 0013382-10.2018.8.26.0041, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Newton Neves. j. 09.11.2018, Publ. 09.11.2018).

À luz de tais precedentes, o regime deve ser o ABERTO, notadamente por força da detração de quase quatro meses.

REVOGO a prisão preventiva de Gustavo, determinando a expedição de alvará de soltura a fim de que possa recorrer em liberdade.

Inviável a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 - SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 - SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que "se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa - e com maior razão."

Para este Juízo não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestarem serviços comunitários.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

Com efeito, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's.

Ressalte-se que os réus estão patrocinados por advogado dativo. Assim, defiro-lhes os benefícios da assistência judiciária, ficando a cobrança suspensa na formado § 3º do art. 98 do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Patrocinados por advogado dativo, honorários na forma do convênio OAB-DPE.

Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso

desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ22. 04.03, p. 253).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se guia de execução definitiva de Elizabete e mandado de prisão no regime aberto para Gustavo. Faculta-se ao réu Gustavo a apresentação em juízo nos dias úteis entre 13:00 e 16:30 para que sua audiência admonitória seja "encaixada" na pauta regular de audiências, evitando-se a intervenção da polícia para o cumprimento do mandado de prisão a fim de preservar o réu de eventuais intercorrências que podem ocorrer, excepcionalmente, em diligências desta natureza. Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; Decreto o perdimento dos valores apreendidos, pois à míngua de comprovação de origem lícita estão claramente vinculados à mercancia de entorpecentes ilegal desempenhada pelos réus. Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA